

포괄임금 합의의 시대사적 의의와 불법성에 관한 고찰

이 준 희*

<국문초록>

포괄임금제는 근로시간 규정의 제도적 유연성이 현재보다 부족하고 사용자의 근로기준법 준수에 관한 인식과 능력이 현저히 낮은 반면 근로자와 노동조합의 사용자에 대한 교섭력이 미약하던 던 시기에, 근로시간 산정 곤란성과 계산 편의, 근로의욕 고취 등을 명목으로 대법원 판례가 형성해온 예외적 법리이다. 현행 근로기준법은 제50조, 제56조, 제58조에 의해 근로시간 계산 및 가산임금 지급 등에 있어서 원칙과 예외의 구조를 정비하여 갖추고 있다. 완벽하지는 않지만 근로시간제도의 유연성을 강화하고 새롭게 등장하는 유형의 일하는 방식에 적용할 수 있는 규범구조를 가지고 있다. 대법원의 판례는 비록 현행 근로기준법의 적용을 통한 포괄임금제 유효성 부정이라는 적극적인 태도를 취하지는 않았지만, 포괄임금제 합의의 성립요건의 엄격화, 포괄임금 적용 대상 항목별 판단, 실제로 수행한 근로시간에 따른 가산임금 지급기준에 미달하는 부분에 대한 무효화 등의 수단을 통해 포괄임금제의 남용을 제어해 왔다. 그러나, 스스로 근로기준법의 명시적인 규정에 반하는 법리를 유지하면서 그 남용을 제한하는 것은 모순적이라고 하지 않을 수 없다. 현행 포괄임금제 및 고정연장근로수당제와 관련한 가장 기본적인 대응 방안은 대법원이 그동안 포괄임금제와 고정연장근로수당제를 허용해오던 사안에 대하여 근로기준법상 재량근로시간제, 간주근로시간제 등 근로기준법 제 58조의 적극적인 적용을 수행하는 것이다. 그러한 전제 하에서 포괄임금제를 일괄 금지하는 입법은 불필요하다. 다만, 산업과 기술의 발전에 따라 새롭게 등장하는 실제로 근로시간 산정이 곤란한 반면 예외적인 유연근무시간제 적용이 예정되어 있지 않은 직무 또는 일자리에 대해서는 일부 예외적인 포괄임금제 합의가 허용될 수 있는 여지는 있을 것이라는 점을 부인하기는 어렵다.

주제어: 포괄임금제, 근로기준법, 근로시간, 임금, 재량근로시간제, 간주근로시간제

논문투고일자: 2025. 12. 3. 심사일자: 2025. 12. 11. 게재확정일자: 2025. 12. 21.

* 법학박사, 광운대학교 법학부 교수

목 차

- I. 문제의 제기
- II. 포괄임금제의 의의와 법적 쟁점
- III. 포괄임금제와 고정연장근로수당제 관련 판례의 흐름
- IV. 포괄임금제와 고정연장근로수당제의 법적 성격
- V. 현행 근로기준법상 포괄임금제와 고정연장근로수당제의 유효성
- VI. 일하는 방식 변화에 따른 포괄임금제와 고정연장근로수당제의 유용성
- VII. 포괄임금제와 고정연장근로수당제 금지 입법 주장에 대한 평가와 반론
- VIII. 맺음말

I. 문제의 제기

포괄임금제는 근로기준법의 강행적 효력에 대한 부정이라고 할 수 있다. 과거 근로기준법이 요구하는 근로조건 보장 수준을 감당할 수 없는 사용자들이 많았고 정부의 감독 역량과 의지도 매우 약하던 시기에 대법원이 예외적으로 그 합법성을 인정한 것이 포괄임금제의 탄생 배경이기 때문이다. 포괄임금제의 불법성을 축소시키기 위해 대법원이 점차 합법성 인정 요건을 제한하고 적용을 엄격하게 통제해왔지만 그와 같은 점진적인 법원의 태도 변화가 포괄임금 합의의 불법성을 완전히 제거하지는 않는다. 더구나, 근로기준법은 근로제공 방식의 다양화와 유연화 경향을 반영하여 근로기준법 제52조의 선택적 근로시간제, 제58조에 근로시간 계산의 특례 등을 규정하여 유연한 상황에 대응할 수 있는 탄력적인 근로시간제도를 입법화했다. 이러한 입법을 통해 포괄임금 합의의 정당성은 그 기초를 거의 완전히 상실했다고 볼 수 있다.

아래에서는 포괄임금 합의가 우리나라에서 형성되어온 배경 및 과정을 자세히 살펴보고(Ⅲ, Ⅳ), 현행 근로기준법 체계 아래에서 포괄임금 합의는 그 합법성이 인정될 수 없다는 점을 논증하고자 한다(Ⅴ). 근로기준법

상의 근로시간 및 임금 규정이 엄격하게 해석되고 적용되는 한 포괄임금 합의를 합법적이라고 인정할 수 있는 근거는 없으며, 현행 근로기준법상의 근로시간 및 임금 규정에 포섭될 수 없는 예외적인 상황에 대해서만 제한적으로만 포괄임금 합의가 가능할 수는 있다는 것이다(VI). 또한 현행 근로기준법의 정확한 해석과 적용을 통해 포괄임금 합의의 인정 범위를 충분히 제한하고 남용을 방지할 수 있다면, 별도의 특별법을 통한 포괄임금제 금지 입법은 불필요하다는 점도 함께 지적하고자 한다(VII).

II. 포괄임금제의 의의와 법적 쟁점

1. 포괄임금제의 의의와 효과

포괄임금제란 사용자와 근로자가 연장근로, 휴일근로에 대한 임금과 가산임금, 미사용 연차유급휴가 수당, 연차유급휴가 근로수당 등 일정 항목의 임금(이하 ‘각종 가산임금과 수당 등’)을 다른 항목의 급여에 포함된 것으로 사전에 합의하고 기본임금에 포함시켜 일괄하여 지급하는 임금지급방법을 말한다.¹⁾ 포괄임금제를 인정하기 시작한 초기에는 포괄임금제를 적용한다는 명목 하에 사용자가 각종 가산임금과 수당 등을 근로자에게 지급하지 않는 편법적인 방법을 뜻했다. 그러나, 1990년대 이후 대법원이 실제 수행한 연장·야간·휴일 근로시간을 계산하여 각종 가산임금과 수당 등을 사후 정산하지 않아도 불법은 아니라고 인정되는 포괄임금제와, 실제 수행한 연장·야간·휴일 근로시간을 계산하여 각종 가산임금과 수당 등을 사후에 정산하여야 하는 고정연장근로수당제를 “근로시간 계산의 곤란성”을 기준으로 나누어 판단하는 경향을 점차 정립해 나가기 시작한 이후에는, 미리 약정된 시간의 길이와 계산 방법에 따라 각종 가산임금과 수당 등을 일괄하여 지급하는 방법까지 포함하는 것으로 포괄임

1) 이준희, 「노동법」, 박영사, 2025, 118쪽.

금제의 정의를 재정리할 필요가 있다. 후자의 방법을 특별히 고정연장근로수당제(소위 ‘고정OT제’)라고 일컫는다. 포괄임금제에는 본래의 통상임금 액수를 미리 산정하지 않은 채 제수당을 합한 금액을 월급여액으로 정하는 임금지급방법을 말하는 정액급제²⁾, 본래의 통상임금 액수를 정한 뒤에 매월 일정액을 제수당으로 지급하는 임금지급방법인 정액수당제³⁾의 두 가지가 있다.

근로자와 사용자 사이의 포괄임금제 합의가 정당한 경우, 근로자가 예를 들어 포괄임금 합의가 되어 있는 연장근로 가산임금의 액수에 해당하는 시간보다 특정일에 더 장시간 연장근로를 한 것을 입증한다 해도 포괄임금제 합의가 유효하므로 사용자가 이를 추가로 계산해서 지급해야 하는 의무가 발생하지 않는다. 그러나, 포괄임금제 합의가 유효하지 않거나 근로시간 산정이 곤란한 경우가 아니어서 고정연장근로수당제라고 보아야 하는 경우에는 근로자가 합의한 연장근로 시간보다 초과하여 연장근로를 한 경우 고정연장근로수당제 합의시 합의된 시간을 전제로 산정된 고정연장근로수당과 실제 연장근로를 한 시간을 기준으로 계산한 연장근로수당과의 차액을 사용자가 근로자에게 지급하여야 한다. 포괄임금제 합의의 유효성 판단요소와 포괄임금제와 고정연장근로수당제의 구별에 관해서는 아래의 논의에서 더욱 구체적으로 정리하기로 한다.

2. 포괄임금제를 둘러싼 법적 쟁점

포괄임금제는 근로기준법이 규정하고 있는 소정근로시간의 제한, 연장근로 등 시간외 근로에 대한 가산임금 지급 의무 등의 규정체계를 전제로, 근로시간의 객관적 산정이 곤란하고 동시에 근로자에게 실질적 불이익이 발생하지 않도록 설계되어 운용되는 경우에 한하여 예외적으로 유

2) 대법원 1982. 3. 9. 선고 80다2384 판결; 대법원 1984. 1. 24. 선고 83도2068 판결; 대법원 1987. 8. 18. 선고 87다카474 판결 등.

3) 대법원 1983. 9. 13. 선고 82다카49 판결; 대법원 1991. 4. 23. 선고 89다카32118 판결; 대법원 2005. 6. 9. 선고 2005도1089 판결

효라고 판례를 통해 인정되어 온 임금계약 관행이다. 대법원은 일찍부터 포괄임금제 합의의 유효성을 인정하면서⁴⁾, 그 포괄임금 약정이 유효하려면, (i) 포괄임금에 관한 명시·묵시의 약정이 존재하여야 하며, (ii) 업무의 성질·형태 등에 비추어 근로시간 산정이 객관적으로 곤란하여야 하고, (iii) 포괄임금제를 적용한 결과가 근로기준법의 최저 기준, 특히 근로기준법 제56조에 따라 산정된 연장·야간·휴일근로 가산임금을 하회하지 않아야 한다는 점을 반복해서 실시하였다.⁵⁾

근로기준법 제15조는 기준에 미달하는 근로조건을 정한 약정을 그 부분에 한하여 무효로 선언한다. 결국 포괄임금제는 원칙적으로 ‘법정 최저 기준 준수’라는 강행규범의 테두리 안에서만 유효성이 인정될 수 있다. 현행 근로기준법은 제50조(1일 8시간·1주 40시간), 제56조(연장·야간·휴일 가산), 제58조(근로시간 계산의 특례: 사업장 밖 간주근로·재량근로)를 통해 유연한 근로시간 및 임금제도 운용을 도모하고 있다. 특히 제58조 제3항은 재량근로시간제를 법정화하고, 시행령 제31조는 그 대상업무를 열거하고, 제58조 제1항과 제2항은 사업장 밖 등 산정 곤란 상황에서 간주시간제를 정하고 있다. 근로기준법상 재량근로시간제와 간주근로시간제는 포괄임금제를 합법적으로 충분히 대체할 수 있는 제도이다. 그럼에도 실무에서는 재량근로시간제나 간주근로시간제보다 포괄임금제와 고정 연장근로수당 약정이 광범위하게 활용되어 왔다.

포괄임금제와 관련하여 이 글은 기본적으로 다음과 같은 관점을 주장하고자 한다. 첫째, 포괄임금제는 근로기준법상 근로시간 규정의 유연성이 상대적으로 부족하던 시기에 판례에 의해 형성된 법리로서, 근로기준법에 정하는 최저 기준을 위반하지 않을 것을 전제로 원칙적으로 사적자치(계약 자유)의 영역에 속한다고 할 수 있다. 둘째, 다만 근로기준법 제58조의 간주·재량근로시간제가 도입된 이후에는 원칙적으로 법제화된 제

4) 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579, 2015다233586 판결; 대법원 2022. 2. 10. 선고 2018다298904 판결.

5) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결; 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결.

도를 우선 적용하는 것이 타당하므로, 포괄임금제는 예외적으로 엄격한 판단요소들을 전체적·종합적으로 고려하여 그 정당성이 판단되어야 한다. 셋째, 고정연장근로수당제는 포괄임금과 구별되는 관행으로서 사용자에게 미지급금액을 정산할 의무를 부과하는 것이 핵심이며, 이를 통해 현행 근로기준법 체계 내에서도 충분히 규율될 수 있다. 넷째, 산업의 디지털 전환, 프리랜서 및 플랫폼 노동 확산 등으로 근로시간의 확정 자체가 어려운 업무가 확대되고 있으므로, 포괄임금제의 예외적 활용 필요성은 향후 오히려 증가할 수 있다. 다섯째, 따라서 포괄임금제와 고정연장근로수당제를 일괄적으로 금지하거나 불법화하는 입법은 바람직하지 않으며, 각종 가산임금과 수당 등에 대한 정산의무의 이행에 대한 감독 강화, 근로기준법 제58조의 유연근로시간제 활용 확대 등을 통해 오히려 합법적이고 합리적인 활용이 가능하도록 이끌어 가는 것이 바람직하다고 생각한다. 아래에서는 각각의 쟁점에 관하여 자세히 살펴보기로 한다.

Ⅲ. 포괄임금제와 고정연장근로수당제 관련 판례의 흐름

대법원이 포괄임금제 합의의 유효성을 인정한 것은 1980년대 초반까지 거슬러 올라간다. 초기 판례는 특정한 사정 아래에서 각종 가산임금과 수당 등을 미리 합산하여 정액으로 지급하는 임금 체계를 유효한 계약으로 볼 수 있다고 설시하는 수준이었다. 대법원 판결의 이와 같은 태도가 근로기준법의 강행력을 무시한 위법한 판단이었다는 점은 의심할 여지가 없다. 이후 1990년대를 지나면서, “근로자의 불이익이 없을 것”, “(계산의) 편의와 근무의욕 고취” 같은 구체적인 유효성 심사기준이 개별 사건에 대한 판례들을 통해 점차 정형화되었고, 2000년대에 들어서는 포괄임금제의 유효성 심사기준을 점차 엄격하게 적용하여, “근로시간 산정의 곤란성”이라는 전제가 없으면 포괄임금제 약정의 유효성을 쉽게 인정하지 않는 방향으로 보정되어 왔다.

1. 개념 및 정당성 인정 요건 형성기

(1) 근로기준법의 엄격한 적용이 불가능하다는 인식의 만연

1953년 근로기준법⁶⁾이 제정되었으나 전후 복구의 시급성, 자원 부족, 영세 사업장 위주의 산업구조 등 구조적 제약 속에서 실제 근로기준법이 산업 현장에서 유효하게 시행되지는 못했던 것으로 보인다. “1950년대에는 産業施設의 미비 등으로 근로감독업무가 사실상 유명무실하였던 것이며 1960년대 이후에는 成長 위주의 경제정책을 실시하면서 급속한 工業化를 이룩하였으나 輕工業과 消費村産業 위주의 경제구조에서 미숙련 근로자의 저렴한 賃金으로 냉혹한 세계시장에서 國際競爭力을 확보하여야 했기 때문에 근로기준법상의 理想은 당분간 휴면상태에 놓여 있었다고 할 수 있고 1970년대에 <중략> 숙련근로자들이 보다 나은 消費生活에 필요한 고액의 賃金을 기대하게 되었음에도 불구하고 이를 충족시키는데 미흡할 수 밖에 없었다.”⁷⁾는 서술은 포괄임금제 관련 대법원 판결이 내려지기 이전 시기의 근로기준법의 규범력이 어떤 수준이었는지 충분히 짐작하게 해준다.

이는 대부분의 산업 기반이 오랜 전쟁으로 파괴된 상황에서 성장 우선 전략 아래 값싼 미숙련 노동력을 기반으로 수출경쟁력을 확보해야 했던 1970년대 까지의 상황에서 결과적으로 법정 근로시간, 임금, 가산임금, 유급휴가 등 근로자의 근로조건 보호와 직결된 근로기준법 규정들의 준수 여부를 엄격히 감독하고 강제하기 어렵다는 인식이 일반화되어 있었다는 점이 요인이 되었을 것이다. 그뿐 아니라, 1981년 ‘노동부’로서 장관급 중앙행정기관으로 승격되기 전까지는 ‘노동국’, ‘노동청’ 등으로 다른 행정 각부, 주로 사회부 산하의 한 부서에 불과했었고, 감독행정에 주력할 수 있을 만큼 충분한 체제와 인력을 확보하지 못하여 만성적인 근로감

6) 1953. 5. 10. 제정, 1953. 8. 9. 시행.

7) 조정찬, “勤勞監督制度 및 勤勞條件自律點檢制度의 現況과 改善方案(下)”, 2009년 등록자료(www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegInfo.mo?mid=a10402020000&mpb_leg_pst_seq=127957. 최종검색일 2025. 11. 15)

독역량 부족 상황에 있었던 점도 근로기준법의 규범력이 관철되지 못하고 있었던 중요한 한 원인이었다고 볼 수 있다.

이러한 상황에서, 현장에서는 포괄임금제, 장시간 근로 등 근로기준법의 규정 및 취지에 반하는 불법적 관행이 광범위하게 정착되었다. 1970년 평화시장의 전태일 선생 분신 사건이 당시까지의 상황을 보여주는 가장 중요한 사례라고 할 수 있다.

(2) 정액수당형 포괄임금의 원칙적 유효 확인

대법원은 1981년 무렵 판결에서 “근로시간 및 근로형태와 그 업무의 성질 등을 참작하여 근로자의 승낙 하에 매월 일정액을 위 제수당으로 지급하는 내용의 계약을 체결하였다고 하더라도 근로자에게 불이익이 없고 제반사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 이를 무효라고 할 수 없다.”라고 하여, “기본임금을 따로 정하고 제수당은 매월 일정액을 지급하는 내용의 근로계약”의 효력을 원칙적으로 유효하다고 보았다.⁸⁾ 이는 제수당을 미리 일정액으로 정하여 기본급과 분리해 정액 지급하는, 이른바 ‘정액수당형’ 포괄임금의 가능성을 초기에 열어 준 판례라고 할 수 있다. 이 판례는 “근로자에 대한 임금은 근로계약에 의하여 기본임금을 결정하고 이에 따른 제수당을 계산하여 합산해야 함이 원칙”이라는 점을 확인하고 있으나, 그와 동시에 강행규정인 근로기준법상 근로시간 및 임금 관련 규정에 부합하지 않는 예외를 인정했다는 점에서 포괄임금 문제의 출발점이라고 지칭할 수 있을 것이다.

(3) 불이익 판단기준의 정립

1981년 대법원 판결 이후 대법원은 포괄임금 약정의 유효성을 더욱 분명히 제시하기 위한 시도를 한다.⁹⁾ 이 시기의 대법원 판결을 보면, “근로계약에 있어 기본임금을 별도로 결정하지 아니하고 제수당을 미리 합산

8) 대법원 1982. 12. 28. 선고 80다3120 판결

9) 대법원 1987.8.18. 선고 87다카474 판결.

한 일정금액을 근로자의 승낙하에 월급여액으로 지급하는 내용의 계약을 하였다 하더라도 단체협약이나 취업규칙에 비추어 근로자에게 불이익이 없고 제반사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 그 계약은 허용된다.”¹⁰⁾라고 하여, 기본임금을 따로 정하지 않고 제 수당을 합산한 일정액을 월급으로 정하는 계약이라 하더라도, (i) 근로자 승낙이 있을 것, (ii) 단체협약·취업규칙 등에 비추어 불이익이 없을 것, (iii) 제반 사정에 비추어 정당할 것을 충족하면 유효하다고 설시하고 있다. 이는 이후 수많은 대법원 판결에서 반복 인용되는 포괄임금제 합의에 대한 유효성 심사의 기본틀이 되고 있다.

(4) “근로시간 및 근로형태와 그 업무의 성질 참작” 필요성 추가

1990년대 들어 대법원은 “근로시간 및 근로형태와 그 업무의 성질 등을 참작하여 근로자의 승낙하에 제수당을 미리 기본임금에 합산한 일정액을 월급여액으로 지급하는 내용의 계약을 체결하였다고 하더라도 단체협약이나 취업규칙에 비추어 근로자에게 불이익이 없고, 제반사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 그 계약은 유효하다고 할 것이다.”¹¹⁾라고 하여, 근로자와 사용자가 포괄임금제 합의를 할 때에는 “근로시간 및 근로형태와 그 업무의 성질 등을 참작”하여야 한다는 점을 새롭게 명시하고, 단체협약 또는 취업규칙에 따른 근로자에게 불이익이 있는지 여부를 세밀하게 판단하고자 하였다.

(5) 고정연장근로수당제 유효성 판단 가능성을 보여주는 사례 등장

대법원은 1992년 판결에서 “포괄임금제의 임금체계에 의한 임금의 지급이 근로자에게 불이익이 없고 정당하다고 인정될 수 있는 것은 근무형

10) 대법원 1982. 3. 9. 선고 80다2384 판결; 대법원 1987. 8. 18. 선고 87다카474 판결 등.

11) 대법원 1991. 4. 23. 선고 89다카32118 판결; 대법원 1992. 2. 28. 선고 91다 30828 판결 등.

태의 특성 그 자체 때문만은 아니고, 포괄임금제의 임금체계에 의하여 임금이 지급되었다고 하더라도 그 지급된 임금에는 법정의 제수당이 미리 포함되어 있다는 사실에 기인하는 것”이라고 하여, “법정의 제수당”이 포괄임금제 합의 시에 합의된 시간에 해당하는 만큼만 포함되어 있는 것이고, “제한 없는 연장근로수당 일체가 포함되어 있다고 보기는 어렵다.”¹²⁾ 라고 하여, 장차 정립될 소위 ‘고정연장근로수당제’의 내용과 유사한 판단을 보여주고 있다. 즉, 포괄임금제 합의가 무제한적으로 사용자의 각종 가산임금과 수당 등의 지급의무를 무제한 면제해주는 것이 아니라는 점을 분명히 하면서, 포괄임금의 포함 범위와 한계를 기술적으로 제시했다는 의의가 있다. 이와 같이 고정연장근로수당제와 유사한 내용의 단체협약의 유효성을 인정한 판결도 1990년부터 이미 등장하고 있었다.¹³⁾

(6) “계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하는 뜻에서 근로자의 승낙하에”

계산의 편의와 직원의 근무 의욕을 고취시키는 취지에서의 포괄임금제 합의의 유효성을 인정한 판례는 비교적 이른 시기부터 발견된다. “시간 외, 야간 및 휴일근무수당을 계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취시키는 취지에서 일정한 실제 근무시간을 기준으로 하여 매월 고정액 또는 금액조정액으로 지급키로 한 것으로서 근로자에게 불이익한 것이 아닌 한 유효하다고 할 것이고, 따라서 근로자가 이러한 근무수당을 이미 지급 받았다면 이와 별도로 휴일근무수당을 청구할 수는 없다.”라고 밝힌 염전회사 직원의 ‘근무수당’ 판결이 대표적이다.¹⁴⁾ 그리고, 1997년 대법원의 청원경찰 판결¹⁵⁾에서 “계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하는 뜻에서 근로자의 승낙하에” 이전 판례에서 요구한 판단요소들에 부합하는 내용의 포괄임금제 임금계약에 합의했다면 그 계약은 유효하다는 판결을 내렸다.

12) 대법원 1992. 7. 14. 선고 91다37256 판결.

13) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90다카6934 판결.

14) 대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카15939 판결.

15) 대법원 1997. 4. 25. 선고 95다4056 판결,

2. 세부적인 쟁점에 관한 법리 형성기

(1) 포괄임금제가 유효한 경우 실제 계산한 연장근로 가산임금과의 차액 문제

포괄임금제 합의가 유효한 경우에, 실제로 계산하여 산출된 연장근로 가산임금과의 차액을 사용자가 근로자에게 지급해야 하는가의 문제에 대해서는, 앞에서 설명한 1997년 청원경찰 판결에서 확인할 수 있는 바와 같이 포괄임금제 합의가 유효하다면 차액을 지급할 필요가 없다는 판례가 확립되어 있었다.¹⁶⁾ 그러나, 고정연장근로수당제와 포괄임금제의 구별에 관한 명확한 인식이 부족한 상황에서 차액 지급 문제에 관하여 분명한 판단을 하기가 어려운 상황이 지속되고 있었다.

그러던 중에 2002년 대법원 판결은 포괄임금제 합의가 유효한 경우라면 사용자가 실제로 계산하여 산출된 연장근로 가산임금과의 차액을 근로자에게 지급할 필요가 없다는 점을 비교적 명확하게 재확인하고 있다.¹⁷⁾ 즉, 대법원은 아파트 경비원이 입주자대표회의와 체결한 포괄임금제 합의에 관하여 판단하면서 “포괄임금제에 의한 임금지급계약이 체결되었다면 원고가 포괄임금으로 지급받은 연장근로수당 또는 이에 갈음한 시간외수당, 야간수당, 휴일수당 등에는 근로기준법의 규정에 의한 시간외근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당이 모두 포함되어 있다고 볼 것이어서, 원심이 그 판시와 같이 원고의 구체적인 시간외 근로시간 등을 인정하고 포괄임금으로 지급된 제 수당과 원심이 인정한 시간외 근로 등에 대한 근로기준법의 규정에 의한 수당과의 차액의 지급을 명한 것에는 포괄임금제에 관한 법리오해의 위법이 있다.”라고 판결하였다. 그러나, 여전히 어떤 경우에 차액을 지급해야 하고, 어떤 경우에 차액을 지급할 필요가 없는지에 관하여는 논란이 남아있을 수밖에 없었다.

¹⁶⁾ 대법원 1997. 4. 25. 선고 95다4056 판결.

¹⁷⁾ 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결.

(2) 동종 사업장의 실태 고려

대법원은 포괄임금제 합의의 유효성을 심사할 때, 이전까지 요구했던 판단요소 외에, “동종 사업장의 실태 등” 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 하여 포괄임금제 합의의 유효성 판단시 고려해야 하는 요소에 “동종 사업장의 실태 등”을 추가했다.¹⁸⁾ 근로자와 사용자가 포괄임금제 합의를 하는 과정에서 신중한 판단을 했는지 여부를 더욱 엄격하게 심사하겠다는 의도인 동시에, 해당 업종의 실제 근로제공 실태를 반영하여 유효성을 인정하겠다는 취지로 이해할 수 있다.

(3) 근로시간 산정 곤란성 없는 포괄임금의 제한과 미달분 합의의 무효성

이전에도 근로시간 산정의 어려움이 포괄임금제의 유효성을 긍정할 수 있는지에 관한 심사기준이 되는 것으로 언급한 판결이 있었다. “경비업무는 근로기준법상의 기준 근로시간을 초과한 연장근로와 야간 및 휴일근무가 당연히 예상되는 반면 실제 근로시간을 산정하는 것이 쉽지 않은 감시 또는 단속적 근로로서, 그와 같은 근로형태의 특수성 때문에 피고는 원고에게 위와 같은 제 수당을 모두 합한 금액을 월 급여액이나 일당 임금으로 정하여 지급하여 왔”다는 판결¹⁹⁾에서 그 내용을 확인할 수 있다.

그러나, 2010년 대법원 판결은 감시·단속적 근로 등과 같이 근로시간 산정이 어려운 경우가 아님에도 근로시간 수와 무관하게 정액의 법정수당을 지급하는 포괄임금 계약을 체결하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다는 점을 강조하면서, 근로시간 산정이 어려운 경우가 아니라면, 그 포괄임금제 합의에 따라 포함된 것으로 간주된 법정수당이 근로기준법 기준에 미달하면 그 미달에 대하여는 포괄임금제 합의가 무효이고, 사용자는 미달 법정수당을 지급하여야 한다고 명시하였다.²⁰⁾ 이는 포괄임금

18) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결; 대법원 2012.3.29. 선고 2010다 91046 판결; 대법원 2020. 6. 11. 선고 2018다206936 판결 등.

19) 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003다66523 판결.

20) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결.

제에 관한 판례 법리가 비교적 넓게 인정해오던 포괄임금제 합의의 유효성을 엄격하게 제한하여 근로기준법의 강행법규로서의 기준에 따라 재정리한 판결로 이해할 수 있다. 아주 중요한 전환점이 되는 판결이라고 할 수 있다. 이 판결은 이후 포괄임금제 합의의 유효성 심사를 엄격하게 하고, ‘고정연장근로수당제’와 ‘유효한 포괄임금제 합의’의 구별을 명확하게 할 수 있는 기준을 제시한 결정적 판결이라고 할 수 있다. 이 판결의 구체적 문구를 보면, “예외적으로 감시단속적 근로 등과 같이 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우에는 사용자와 근로자 사이에 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나 기본임금을 미리 산정하면서도 법정 제수당을 구분하지 아니한 채 일정액을 법정 제수당으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다 할 것이다. 그러나 위와 같이 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 달리 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 앞서 본 바와 같은 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 할 것이므로, 이러한 경우에도 근로시간 수에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하는 내용의 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결하는 것은 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다.”라고 상당히 엄격하고 제한적인 내용으로 포괄임금제의 유효성 심사기준을 정리하고 있다. 판결의 내용만을 놓고 봤을 때 전원합의체 판결에 준하는 파급력을 가지고 있다고 생각된다. 이러한 기조는 이후의 대법원 판결에서도 유지되고 있다.²¹⁾

21) 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결; 대법원 2024. 2. 8. 선고 2018다206899 판결 등.

(4) 포괄임금제에 관한 묵시적 합의의 유효성

대법원은 단체협약, 취업규칙, 개별 근로계약 등에 명시적인 포괄임금제 적용에 관한 합의가 없더라도 일정한 경우에 묵시적인 합의에 의한 포괄임금제 합의의 유효성을 긍정하고 있다. “묵시적 합의에 의한 포괄임금 약정이 성립하였다고 인정하기 위해서는, 근로형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로 시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 그 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우이어야 할 것이다.”²²⁾라는 판결이 그것이다.

(5) 각종 가산임금과 수당 등에 관한 세부적 지급기준이 있을 경우 유효성 부정

단체협약 또는 임금협정서 등에 포괄임금제에 합의한다는 취지가 기재되어 있다 하더라도, 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우에는 포괄임금제 합의가 유효하게 이루어졌다고 볼 수 없다는 법리가 제시된다. 이는 포괄임금제라는 문언이 아니라 실제 규정되어 운영되는 임금체계의 구조를 포괄임금제 합의의 유효성을 판단하는 요소로 고려하겠다는 점을 분명히 한 것으로서 의미가 있다.

여기까지 이르면, 대법원은 포괄임금제에 관한 약정이 유효하게 성립하였는지는 여부를 판단함에 있어서, 긍정적인 판단요소로 (i) 근로시간, 근로형태와 업무의 성질 등을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 경우로서, (ii) 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의

22) 대법원 2021. 11. 11. 선고 2020다224739 판결; 대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1060 판결 등.

실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단하여야 하고, 부정적인 판단요소로서 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우에는 포괄임금제에 해당하지 않는다는 판단 기준을 정립한 것으로 정리할 수 있다. 이러한 판례의 태도는 노선버스 운전기사에게 적용되는 단체협약에 관한 판결²³⁾에서 나타나는 “포괄임금제에 관한 약정이 성립하였는지는 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단하여야 한다. 비록 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상된다고 하더라도 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우에는 포괄임금제에 해당하지 아니한다. 그리고 단체협약 등에 일정 근로시간을 초과한 연장근로시간에 대한 합의가 있거나 기본급에 수당을 포함한 금액을 기준으로 임금인상률을 정하였다는 사정 등을 들어 바로 위와 같은 포괄임금제에 관한 합의가 있다고 선불리 단정할 수는 없다.”는 문구에서 확인할 수 있다.

3. 부수적인 쟁점에 관한 법리 제시

(1) 항목별 유효성 판단 가능성 인정

한편 부수적인 쟁점으로, 대법원은 2022년 버스운송사업 임금협정에 규정된 포괄임금제 합의의 유효성을 둘러싼 사건에서, 연장·야간근로수당에 대해서는 포괄약정의 성립을 긍정하면서도 휴일근로수당에 대해서는 별도의 규정·운영 실태를 고려하여 달리 판단할 수 있음을 실시하였다.²⁴⁾ 이는 포괄임금제 합의의 유효성 판단이 수당 항목별로 분화될 수

²³⁾ 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579, 2015다233586 판결.

²⁴⁾ 대법원 2022. 2. 10. 선고 2018다298904 판결.

있다는 점을 확인한 것이다.

(2) 고정연장근로수당과 통상임금 해당성의 문제

고정연장근로수당이 통상임금에 해당하는지 여부는 소정근로의 대가로서 정기적·일률적으로 지급되는 금품에 해당되는 것으로 볼 수 있는가²⁵⁾ 하는 판단에 따라 달라질 수 있다. 그러나, 고정연장근로수당 합의에 따라 지급된 고정수당을 통상임금으로 판단하면 통상임금 총액이 증가하고, 통상임금 총액이 증가하면 시간 단위로 산정하여 지급되는 고정연장근로수당이 증가하고, 고정연장근로수당이 증가하면 다시 통상임금 총액이 증가하는 연쇄효과가 발생하여 고정연장근로수당과 통상임금이 무한대로 증가하는 순환증폭의 오류가 발생하게 된다. 이 쟁점이 월급제 사무직에게 지급된 ‘고정시간외수당’을 둘러싸고 발생한 사건에서 대법원은 해당 고정시간외수당이 소정근로의 대가가 아니라는 근거로 통상임금에 해당하지 않는다고 판단하였다.²⁶⁾

4. 소결

이상에서 살펴본 포괄임금제 합의의 유효성과 관련한 대법원의 판례법리를 간단하게 정리하면, 유효성 인정을 위한 필수 판단 요소로서 (i) 근로제공 형태와 업무의 성질 등을 고려한 근로시간 산정의 곤란함, (ii) 대상 근로자 불이익이 없을 것, (iii) 명시적 또는 묵시적은 근로자와의 합의의 존재를 요구하고 있다고 정리할 수 있다. 포괄임금 합의의 유효성을 심사함에 있어서 대법원은 초기의 완화된 판단요소 제시에서 나아가 시간이 지날수록 판단요소를 추가하고, 무엇보다 근로시간, 근로형태와 업무의 성질 등을 고려할 때 근로시간 산정이 곤란한 경우에만 포괄임금제

25) 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결; 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결.

26) 대법원 2021. 11. 11. 선고 2020다224739 판결.

합의가 유효한 것으로 요건을 엄격화 하면서, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하도록 법리를 다듬고 세밀화해 왔다. 이와 같은 대법원의 판례의 흐름은 근로기준법의 규정에 반하는 포괄임금제도 합의의 유효성을 인정한 것이 타당한지에 대한 논의는 별론으로 하더라도, 근로기준법상 근로시간 및 임금, 가산임금 규정의 규범력을 회복하는 방향성이 있는 것으로 볼 수 있으므로 원칙적으로 바람직하다고 할 수 있다.

포괄임금제와 관련한 대법원 판례를 살펴보면, 개개의 판단들이 장시간의 판결의 축적과 사후의 변경 등을 통해서 소위 ‘법리’라고 인정 할 수 있는, 위에 정리한 내용으로 수렴해오기는 했지만 모든 판결들이 엄격한 일관성을 유지하여 결론을 내리고 있다고 보기는 어렵다. 그리고, 1998년 2월 20일 근로기준법 개정시에 재량근로시간제와 간주근로시간제가 명시적으로 도입되어 규정된 이후에는, 대법원이 별도로 포괄임금제와 고정연장근로수당제 합의의 유효성을 인정하는 판례 법리를 폐기했어야 한다고 생각된다.

IV. 포괄임금제와 고정연장근로수당제의 법적 성격

1. 종래의 논의

종래의 일부 정리를 보면, 포괄임금제의 법적성격을 포괄임금제의 인정 범위와 대상 업무를 나누어 각각을 엄격해석론과 확대해석론의 관점이 있는 것으로 분류하여 기술하고 있다.²⁷⁾ 엄격해석론과 확대해석론으로 나누어 포괄임금제 합의의 법적성격을 검토하는 논의 방법은 1990년대 이후 판례²⁸⁾가 점차 포괄임금제와 고정연장근로수당제를 구분하여 판

27) 하갑래, 「근로기준법(제37판)」, 2025. 424쪽 이하.

28) 대법원 1992. 7. 14. 선고 91다37256 판결; 대법원 1990. 11. 27. 선고 90다카

단하기 시작한 이래 2010년에 이르러²⁹⁾ 그러한 구별 법리를 명시적으로 확립한 이후에는 더 이상 정확한 관점이라고 보기 어렵다고 생각된다.

2. 포괄임금제와 고정연장근로수당제 각각의 법적 성격

(1) 포괄임금제의 법적성격

포괄임금제는 법률이 직접 규정한 제도가 아니라, 임금 구성·지급 방법에 관한 근로계약 당사자 사이의 특약에 해당한다. 이와 같은 약정의 유효성은 대등한 당사자 사이의 합의라고 인정된다면 근로기준법 제4조에 의해 인정될 수 있다. 다만 그 합의의 내용이 강행법규인 근로기준법의 최저 기준에 미달하는 경우에는 그 부분이 근로기준법 제15조에 따라 무효가 되고, 그 미달하는 부분은 근로기준법이 정하는 법정 기준에 따라 추가 지급되어야 한다.³⁰⁾ 포괄임금제 합의가 유효한 경우는 기본적으로 “근로시간의 산정이 곤란한 경우”이어야 하는데, 근로시간의 산정이 곤란한 경우에는 근로기준법 제58조 제1항과 제2항에 규정되어 있는 간주근로시간제 또는 근로기준법 제58조 제3항에 규정된 재량근로시간제를 활용하여야 하는 것이 원칙이다.³¹⁾ 근로기준법은 강행법규이기 때문이다.

장거리 노선 여객 운송업, 장거리 화물 운송업, 공기를 확정하기 어려운 건설현장, 경비 업무 등 감시·단속적 업무 등 대법원 판결이 근로시간의 산정이 어렵다는 이유로 포괄임금제 합의의 유효성을 인정하는 대부분의 업종에 대해 근로기준법에 따라 재량근로시간제 합의나 간주근로시간제 합의를 하도록 하는 것이 타당하고, 굳이 포괄임금제라는 법외(法外) 제도의 유효성을 인정할 필요는 없다고 생각된다.

6934 판결.

29) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결.

30) 김형배, 「노동법(제27판)」, 2021. 227쪽 이하; 임종률·김홍영, 「노동법(제22판)」, 2025. 343쪽

31) 박은정, ‘임금의 개념에 비추어 본 포괄임금약정’, 「법제논단(vol.710)」, 법제처, 2025. 209쪽 이하도 같은 취지로 이해된다.

(2) 고정연장근로수당제의 법적 성격

고정연장근로수당제도 통상 월·주 단위로 일정 시간분의 연장근로 또는 휴일근로 등에 대한 가산임금을 고정액으로 선지급하고, 실근로시간과의 차이는 사후 정산하는 체계를 전제로 하는 근로계약 당사자 사이의 특약이다. 임금 및 근로시간 관리의 편의성, 예측가능성 등의 장점이 있으나, 사용자가 정산을 누락하거나 실제 연장근로 시간에 미달하는 내용으로 설계하고 합의하는 경우 근로기준법 위반·임금체불 문제가 발생한다.

V. 현행 근로기준법상 포괄임금제와 고정연장근로수당제의 유효성

1. 현행 근로기준법의 규범 틀과 우선순위

1998년 2월 20일에 근로기준법 제56조 제3항이 신설되어 재량근로시간제가 도입되었으며, 근로기준법 제56조 제1·2항이 신설되어 간주근로시간제가 도입되었다. 해당 조항들은 몇 차례의 근로기준법 개정 과정에서 조문 번호가 변경되어 현재는 근로기준법 제58조 제1항과 제2항이 간주근로시간제, 근로기준법 제58조 제3항이 재량근로시간제를 규정하고 있다.

현행 근로기준법 하에서 근로기준법 제50조, 제56조, 제53조 등 근로시간, 연장근로 가산임금 등의 규정은 강행규정으로서 반드시 준수되어야 한다. 그리고, 근로시간의 산정이 본질적으로 곤란하거나 업무수행 방법이 근로자의 재량에 맡겨지는 경우에는 제58조를 통해 제도적 유연성이 제공된다. 특히 제58조 제3항의 재량근로제는 근로기준법 시행령 제31조가 규정하는 대상업무에 한해 근로자대표와의 서면합의로 간주시간을 정할 수 있다. 이와 같은 근로기준법 체계 아래에서 포괄임금제는 근로기준법 제58조를 대체하는 일반해결책이 아니라, 제58조로 포섭할 수 없는 특

수한 경우에만 예외적으로 그 유효성이 인정될 수 있는 보충적인 특약상 제도로 인식되어야 한다.

2. 근로기준법 제58조 입법 이후의 포괄임금제 합의의 유효성

현행 근로기준법의 강행성과 조문의 체계에 비추어 보면, 간주근로시간제와 재량근로시간제가 도입된 이후에는 근로계약 체결 당사자 또는 단체협약 체결 당사자 사이의 포괄임금제 합의의 유효성을 인정하는 것은 타당하지 않다.

그 이유는 다음과 같다. 첫째, 무엇보다 근로기준법 제56조는 연장·야간·휴일근로에 대한 가산임금을 강행규정으로 명시하고 있다. 강행규정의 취지는 계약 당사자가 합의를 통해 법정 최저 기준을 우회·잠식하지 못하게 하는 데 있다. 대법원은 특히 고정연장근로수당제의 유효성과 관련하여 포괄임금 약정이 존재하더라도 그에 포함된 법정수당이 법 기준에 미달하는 부분은 무효이며, 미달분은 추가 지급의무가 발생한다는 법리를 견지해왔다. 그러나, 근로기준법 제58조가 존재함에도 불구하고, 근로계약 체결 당사자가 그에 반하는 별도의 합의를 하는 것을 유효하다고 인정한 뒤에 다시 이를 제한하는 법리를 구성하는 것은 근로기준법 제58조의 입법취지를 몰각시키고 그 조항을 사문화하는 결과를 가져올 것이다. 둘째, 근로기준법 제58조가 포섭하는 규율영역, 즉 근로시간 산정이 곤란한 경우는 연혁적으로 포괄임금제 합의가 허용되는 영역과 상당 부분 중첩된다. 제58조 제1항과 제2항은 사업장 밖 등 산정 곤란 상황에서 간주시간을 정하게 하고, 제3항은 재량근로를 도입하면서 대상업무 특정, 근로자대표와의 서면합의, 사용자의 출근 지시금지 등 절차적 안전장치를 요구한다. 이는 ‘근로시간 산정 곤란’이라는 포괄임금제를 통해 해결하려고 하는 상황과 동일한 문제를 법정 절차로 해결하는 경로를 마련한 것이다. 그러므로 산정 곤란을 이유로 포괄임금을 인정하는 것은 제58조의 엄격한 요건을 사인간의 합의를 근거로 우회하는 것을 합법이라고 인정하

는 결과를 초래할 수 있다. 따라서, 근로기준법의 효력과 법률의 해석 및 적용의 일반 원칙을 고려할 때 동일 또는 유사한 사안에 대해서는 근로기준법 제58조를 적용하는 것이 포괄임금제 합의의 유효성을 인정하는 것보다 우선되어야 한다. 즉, 근로기준법 제58조에 따라 근로자 대표와의 서면합의를 통해 제도를 설계하고 운영해야 하는 사항에 대하여 근로기준법 제58조의 규정을 따르지 않고 포괄임금제로 우회하는 것의 유효성을 인정해서는 안 된다.

최근 대법원 판례³²⁾가 포괄임금제 합의의 유효성을 판단할 때 더욱 엄격한 기준을 적용하는 것은 앞에서 설명한 바와 같이 바람직한 방향 선회이자 오류의 보정이라고 볼 수 있다. 하지만, 여전히 현행 근로기준법의 명시적 규정보다 판례를 통해 조성되어온 포괄임금제 법리를 우선한다는 측면에서는 그 정당성에 문제를 제기하지 않을 수 없다. 포괄임금제 합의의 유효성에 관한 판단 기준도 대법원이 제시한 기준들이 되어서는 곤란하다. 근로기준법 제58조가 그 판단기준이 되어야 할 것이다. 이를 통해 근로기준법 제58조에 대한 해석론을 더욱 정치학계 발전시켜 나가는 것이 올바른 법률 적용 및 운용 방향일뿐만 아니라, 근로계약 당사자들의 예측가능성을 더욱 강화하는 방법일 것이다.

물론 이에 대해서는 입법체계 측면에서 근로기준법 제58조는 ‘근로시간 계산의 특례’를 정한 것일 뿐, 포괄임금제 합의의 대상이 되는 모든 사항들을 규율하기 위해 마련된 규정이 아니며, 현장의 다양성과 산정 비용 등을 고려하면 근로기준법 제58조를 적용하여 근로자 대표와의 서면합의를 요구하고, 대상업무를 제한하는 등 엄격한 절차적, 내용적 정당성을 요구하는 것은 현장 노동력 제공관계의 유연성과 노사간의 자치를 해하고 지나치게 경직성을 강화하는 결과가 된다는 비판이 가능하다. 그리고, 사업장 외 근로 또는 이동이 많은 근로와 프로젝트형 업무가 증가하고, 근로제공의 형태와 내용이 급변하는 플랫폼 산업 등에서는 포괄임금제를 허용하는 것이 거래비용을 낮추는 중간제도로 기능할 수 있으며, 대법원

32) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결 등.

판례가 이미 포괄임금제 합의의 유효성을 상당히 제한적으로 인정하고 있기 때문에 남용의 가능성이 낮다는 반론이 제기될 수 있다. 그러나, 그와 같은 상황논리로 강행법규의 적용을 제한하는 것은 타당한 법률 적용 태도라고 할 수 없다. 그러한 법률 경시 태도는 당연히 사법부와 입법부의 권력분립 원칙의 침해에 해당할 수 있으며, 근로기준법 제58조를 적용하는 것이 대법원의 판례 법리에 따른 포괄임금제 또는 고정연장근로수당제 합의의 유효성 인정기준에 비추어보았을 때 지나치게 경직적이라고 볼 것은 아니며, 근로기준법 제58조는 노사간 자치의 영역을 오히려 확보하는 방향으로 설계되어 있다는 반론을 충분히 제기할 수 있다.

VI. 일하는 방식 변화에 따른 포괄임금제와 고정연장근로수당제의 유용성

1. 근로시간과 성과 사이의 관련성의 약화와 근로자의 재량 강화 경향

최근들어 디지털 전환, AI 도입, 플랫폼 협업의 고도화에 따라, 근로자의 개인적 판단에 의존하는 창작, 연구개발, 설계, 편집, 제작 등 근로제공의 길이보다는 작업의 성과가 더 중요한 노동력 제공 및 활용 방식이 일반화되는 영역이 점차 확대되고 있다. 이러한 영역에서는 출퇴근 시간·물리적인 사업장 체류시간 등이 생산성과 밀접하게 연동되지 않거나, 사업장 외에서의 모바일·원격 업무가 파편적으로 이루어져 근로시간의 확정 자체가 곤란한 경우가 크게 늘어나고 있다. 물론 근로기준법 제58조에 따른 재량근로시간제와 간주근로시간제가 1차적으로 적용되어야 하지만, 근로기준법 시행령 제31조의 열거 대상업무에 해당하지 않는 새로운 유형의 업무, 예를 들면, 전형적인 클라우드워크에 해당하는 데이터 큐레이션, 모바일 디지털 기기를 활용한 각종 플랫폼 노동의 유형 등에 대해서는 재량근로제를 적용하는 과정에서 해석상 불명확성이 존재할 가능성도

배제할 수 없다. 이때 엄격한 요건 하에서 포괄임금제를 활용하는 것이 거래비용과 규범 불확실성을 낮추는 보충적 안전판이 될 수도 있다는 점을 부정할 수는 없다.

2. 포괄임금제와 고정연장근로수당제의 긍정적 기능

위와 같은 상황에서라면 포괄임금제는 (i) 근로기준법 제58조 틀의 적용이 곤란한 과도기적 업무·혼합형 직무에서 한시적으로, (ii) 근로기준법이 정하는 근로조건의 기준에 미달하지 않도록 설계·정산되는 것을 전제로, (iii) 근로자 대표와의 투명한 합의를 통해 예외적인 제도로 운용할 때에 한정하여 그 유효성을 인정할 수 있을 것이다.³³⁾ 물론, 이 경우에도 포괄임금제 합의는 남용되어서는 안 되며, 근로시간을 정확히 기록하고 정산하며³⁴⁾, 근로자에게 통지하도록 사용자에게 부과된 의무를 엄격하게 준수하도록 하는 것이 전제되어야 한다.

특히, 근로시간의 산정이 곤란하지 않지만, 근로시간 운영의 유연성을 고도로 확보해야 하는 영역에서는 고정연장근로시간제는 (i) 임금의 예측가능성을 제고하고, (ii) 중소기업 조직의 효율적인 급여 운영을 가능하게 하며, (iii) 성수기·비수기의 변동성으로 인한 계산의 곤란성을 낮추는 데에 기여할 수 있으므로 여전히 의미가 있다.

33) 김홍영, ‘포괄임금제 법리의 새로운 검토’, 『성균관법학(제23권 제3호)』, 성균관대학교 법학연구원, 2011, 855쪽의 취지도 유사한 문제의식에 근거한 것으로 이해된다.

34) 김기선, ‘포괄임금제와 근로시간의 기록·관리’, 『법과 정책연구(제20집 제1호)』, 한국법정책학회, 2020, 149쪽 이하 참조.

VII. 포괄임금제와 고정연장근로수당제 금지 입법 주장에 대한 평가와 반론

1. 포괄임금제 금지입법의 주요 내용

금지입법을 주장하는 측은 포괄임금제가 “실근로시간과 무관한 정액지급 관행”을 고착화하여 가산임금(연장·야간·휴일)을 사실상 무력화하고, 장시간 노동과 임금체불 위험을 구조화한다고 본다. 따라서 법률에 포괄임금계약의 원칙적 금지를 명문화하고, 예외가 필요한 경우에도 엄격한 절차적 통제를 두어야 한다고 주장한다. 최근 국회에 발의되어 있는 여러 근로기준법 개정안은 공통적으로 ① 포괄임금계약을 원칙적으로 금지 또는 제한하고, ② 예외적으로 허용하는 경우에도 근로시간 산정이 객관적으로 곤란한 경우로 제한하며, ③ 사용자의 근로시간 측정·기록 의무를 강화하고, ④ 정액급제·정액수당제 등 포괄 유형의 명시적 금지, ⑤ 근로자대표와의 협의 및 고용노동부 장관의 인가나 행정관청에의 신고 등의 절차를 담는 방향으로 설계되어 있다. 이러한 방향은 소위 “공짜 야근 근절”이라는 문구로 대변되는 사회적 요구가 있다는 것을 전제로 다수 법안으로 구체화되었다.

먼저 박홍배 의원 대표발의안³⁵⁾은 사용자가 근로계약을 체결하는 경우 연장·야간 및 휴일근로에 따라 가산되는 금액을 각 항목별로 구분하지 않거나 이를 기본급에 포함시키는 형태의 ‘포괄임금계약’을 금지하는 동시에, 임금대장의 기재사항에 ‘실제 근로일수 및 근로시간수’를 추가하고, 근로자가 임금대장에 대한 열람 또는 사본 교부를 요청할 수 있도록 하는 것을 주요 내용으로 한다. 둘째, 박주민 의원 대표발의안³⁶⁾은 포괄임금계약의 금지를 명시적으로 규정하는 한편, 사용자로 하여금 근로자의 업무개시 및 종료 시간을 측정·기록하도록 하고, 해당 규정들의 실효성 확보

35) 의안번호 2202812, 2024. 8. 13. 발의.

36) 의안번호 2203885, 2024. 9. 10. 발의.

를 위하여 포괄임금계약 금지 위반 시 과태료를 부과하는 것을 주요 내용으로 한다. 셋째, 박해철 의원 대표발의안³⁷⁾은 포괄임금계약이 장시간 노동 관행을 고착시키고 건강권·일·가정 양립을 해친다는 문제의식을 전면에서 두고, 포괄임금계약을 제한하는 내용의 근로기준법 개정을 제안한다. 주요 내용은 장시간 근로의 주요 원인으로 지적되고 있는 포괄임금계약을 제한하고, 사용자로 하여금 근로시간과 휴게시간 등을 기록하고 고용노동부장관에게 신고하도록 하고 있다. 넷째, 천하람 의원 대표발의안³⁸⁾은 포괄임금제를 원칙적으로 금지하되 근로시간 산정이 어려운 경우 사용자가 근로자대표와의 협의를 통해 고용노동부장관의 인가와 근로자대표의 동의를 받도록 하는 것을 주요 내용으로 한다.

위의 개정안들은 포괄임금제 및 고정연장근로시간제가 장시간 근로를 구조화하고, 근로자들이 가산임금 등을 받을 수 있는 권리를 침해한다는 공통된 인식 위에, 포괄임금계약을 원칙적으로 금지하거나 제한하고, 고용노동부 장관에 대한 신고나 인가, 근로자 대표의 동의 등을 요건으로 예외적으로 인정하는 것을 기본 틀로 한다. 또한, 사용자의 근로시간과 휴게시간 기록의무를 명시하는 것을 공통적 특징으로 하며, 포괄임금제 금지 의무를 위반하는 경우 과태료를 부과하도록 하는 경우도 있다.

2. 포괄임금제 금지입법의 실효성에 대한 의문

그러나 근로기준법 제15조, 제56조, 제58조는 이미 강력한 강행 규범으로서 기능한다. 포괄임금제 합의가 유효하다 하더라도 기준 미달 부분은 당연히 무효이고 미달분 지급의무가 발생한다³⁹⁾. 또한 대법원은 포괄임금제 합의의 성립 자체를 엄격하게 보고⁴⁰⁾, 항목별 분리 판단도 활용하여

37) 의안번호 2200760, 2024. 6. 20. 발의.

38) 의안번호 2211689, 2025. 7. 23. 발의.

39) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결; 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결.

40) 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579, 2015다233586 판결

남용을 제어하는 법리를 형성해 왔다.⁴¹⁾ 즉, 현행 체계를 엄격히 운용하고 행정관청이 감독 의무를 성실히 수행한다면 사용자가 각종 가산임금과 수당 등을 제대로 지급하지 않거나 지급하지 않는 것을 근로계약의 내용으로 담는 문제를 상당부분 해결할 수 있다.

오히려 포괄임금제를 일괄하여 금지하는 입법은 (i) 근로기준법 시행령 제31조가 열거하는 재량근로시간제 적용 대상 업무 밖의 신종·혼합형 업무에 대한 합리적인 대가 설계가능성을 위축시키고, (ii) 프로젝트형 또는 성과형 산업에서 당사자 사이의 자율적 근로조건 형성 가능성 및 예측가능성을 저해하며, (iii) 결국 비공식적이고 편법적인 보상체계의 형성을 초래할 수 있는 소지가 있다. 오히려, 사용자에 대한 미지급 임금 정산의무 부여, 근로시간 정보에 대한 기록 및 공개 의무화 등이 장기적으로는 비용이나 효율 측면에서 우월하다고 생각한다.

VIII. 맺음말

포괄임금제는 근로시간 규정의 제도적 유연성이 현재보다 부족하고 사용자의 근로기준법 준수에 관한 인식과 능력이 현저히 낮은 반면 근로자와 노동조합의 사용자에 대한 교섭력이 미약하던 던 시기에, 근로시간 산정의 곤란성과 계산 편의, 근로의욕 고취 등을 명목으로 대법원 판례가 형성해온 예외적 임금계약 법리이다. 현행 근로기준법은 제50조, 제56조, 제58조에 의해 근로시간 계산 및 가산임금 지급 등에 있어서 원칙과 예외의 구조를 정비하여 갖추고 있다. 완벽하지는 않지만 근로시간제도의 유연성을 강화하고 새롭게 등장하는 유형의 일하는 방식에 적용할 수 있는 규범구조를 가지고 있다. 대법원의 판례는 비록 현행 근로기준법의 적용을 통한 포괄임금제 유효성 부정이라는 적극적인 태도를 취하지는 않았지만, 포괄임금제 합의의 성립요건의 엄격화, 포괄임금 적용 대상 항목별

41) 대법원 2022. 2. 10. 선고 2018다298904 판결.

판단, 실제로 수행한 근로시간에 따른 가산임금 지급기준에 미달하는 부분에 대한 무효화 등의 수단을 통해 포괄임금제의 남용을 제어해 왔다. 그러나, 스스로 근로기준법의 명시적인 규정에 반하는 법리를 유지하면서 그 남용을 제한하는 것은 모순적이라고 하지 않을 수 없다.

현행 포괄임금제 및 고정연장근로수당제와 관련한 가장 기본적인 대응 방안은 대법원이 그동안 포괄임금제와 고정연장근로수당제를 허용해오던 사안에 대하여 근로기준법상 재량근로시간제, 간주근로시간제 등 근로기준법 제58조의 적극적인 적용을 수행하는 것이라고 생각한다. 그러한 전제 하에서 포괄임금제를 일괄 금지하는 입법은 불필요하다. 다만, 산업과 기술의 발전에 따라 새롭게 등장하는 실제로 근로시간 산정이 곤란한 반면 예외적인 유연근무시간제 적용이 예정되어 있지 않은 직무 또는 일자리에 대해서는 일부 예외적인 포괄임금제 합의가 허용될 수 있는 여지는 있을 것이라는 점을 부인하기는 어렵다. 디지털 전환과 근로제공 방식의 다양화가 점차 가속되어 가는 가운데 근로시간 확정이 어렵거나 불필요한 업무가 증가할 수 있으며, 이 영역에서의 예외적 포괄임금제 합의는 보충적 완충재로서 기능할 여지가 있기 때문이다.

참고문헌

김형배, 「노동법(제27판)」, 2021

임종률·김홍영, 「노동법(제22판)」, 2025

이준희, 「노동법」, 박영사, 2025

하갑래, 「근로기준법(제37판)」, 2025

조정찬, “勤勞監督制度 및 勤勞條件自律點檢制度의 現況과 改善方案(下)”,
2009년 등록자료

김기선, ‘포괄임금제와 근로시간의 기록·관리’, 「법과 정책연구(제20집 제
1호)」, 한국법정책학회, 2020

김홍영, ‘포괄임금제 법리의 새로운 검토’, 「성균관법학(제23권 제3호)」,
성균관대학교 법학연구원, 2011

박은정, ‘임금의 개념에 비추어 본 포괄임금약정’, 「법제논단(vol.710)」,
법제처, 2025

판례검색

<https://casenote.kr/>

<https://portal.scourt.go.kr/pgp/index.on>

<Abstract>

A Study on the Evolution of Case Law Concerning
Comprehensive Wage Agreements and the Illegality of
Such Agreements

Lee, Junheui*

The comprehensive wage system in Korea is an exceptional doctrine of wage contracting that has been developed by Supreme Court case law at a time when the institutional flexibility of working-time regulation was lower than it is today, employers' awareness of and capacity to comply with the Labor Standards Act (LSA) were markedly deficient, and workers and trade unions had only weak bargaining power vis-à-vis employers, under the pretexts of difficulty in calculating working hours, convenience of calculation, and the promotion of work motivation. Articles 50, 56 and 58 of the current LSA have now established a structure of rules and exceptions governing the calculation of working hours and the payment of premium wages. Although this framework is not perfect, it enhances the flexibility of working-time arrangements and provides normative structures that can be applied to newly emerging forms of work. While the Supreme Court's case law has not taken the further step of affirmatively denying the validity of comprehensive wage schemes under the current LSA, it has sought to curb their abuse by tightening the requirements for the formation of comprehensive wage agreements, by assessing their applicability item by item, and by

* Professor, College of Law and Public Policy, Kwangwoon University / PhD in Law

invalidating any portion that falls short of the standard of premium wages based on the actual hours worked. However, maintaining a doctrine that runs counter to the explicit provisions of the LSA while at the same time seeking to limit its abuse is difficult to regard as anything other than self-contradictory.

With respect to the current comprehensive wage system and fixed overtime allowance schemes, this paper argues that the most basic response is for the Supreme Court, in those cases in which it has thus far permitted such arrangements, to actively apply Article 58 of the LSA, including the discretionary working hours system and the deemed working hours system. On this premise, legislation that imposes a blanket statutory prohibition on comprehensive wage schemes is unnecessary. Nevertheless, it is difficult to deny that, in light of industrial and technological developments, there remains some room to permit exceptional comprehensive wage agreements for certain jobs or positions where it is genuinely difficult in practice to determine working hours and where the application of existing exceptional flexible working-time schemes is not envisaged. As digital transformation accelerates and modes of providing labor become more diverse, work for which the determination of working hours is difficult or unnecessary is likely to increase, and in these areas exceptional comprehensive wage agreements may have room to function as a supplementary buffer mechanism.

Key Words: Wage, Comprehensive wage system, Working hours, Labor Standards Act, discretionary working hours system, deemed working hours system